Processo nº **0050111-19.2021.8.17.2001**

AUTOR: MARIA TERESA SANTANA AMARAL

REU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

MARIA TERESA SANTANA AMARAL ajuizou ação em face de **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, buscando a condenação da demandada a: (i) autorizar e custear o tratamento com a medicação PROLIA (Denosumab) 60mg/ml, de uso domiciliar, por tempo indeterminado, na frequência de 1 (uma) injeção subcutânea a cada 6 (seis) meses; (ii) alternativamente, reembolsar a parte autora das despesas havidas, nos termos da prescrição médica, sendo apurados os valores em fase de liquidação de sentença; (iii) pagar-lhe R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Alega, em resumo, que:

a) é beneficiária de contrato de assistência à saúde antigo e não adaptado, categoria individual, e cobertura hospitalar e ambulatorial com obstetrícia, firmado entre as partes há mais de 35 (trinta e cinco) anos;

b) foi diagnosticada há mais de 5 (cinco) anos como portadora de Osteoporose em Progressão (CID M81.0), apresentando perda mineral óssea, dores e dificuldade de locomoção;

c) em tratamento à patologia, o médico que a assiste prescreveu bisfosfonato, todavia, o uso contínuo e prolongado da substância, além de não estar impedindo a perda de massa mineral óssea, passou a ser contraindicado por expô-la a maior risco de fraturas;

d) diante do quadro de evolução da doença, e dos riscos decorrentes do uso prolongado da medicação inicialmente prescrita, o especialista receitou, em alternativa, o uso de PROLIA (Denosumabe). Todavia, a operadora de saúde recusou custear o tratamento.

Requereu a gratuidade judiciária e a tramitação prioritária do feito por ser idosa.

Pediu que, em sede de tutela provisória de urgência, fosse a demandada compelida a autorizar e custear imediatamente o tratamento com a medicação prescrita.

Instada (ID 84357419), a parte autora juntou o contrato de assistência à saúde pactuado com a ré (ID 84688850).

Intimada a se manifestar sobre o pleito provisório (ID 84357419), a parte ré apresentou resposta, na forma de contestação (ID 85213473). Requer, preliminarmente, o chamamento ao processo do Estado de Pernambuco. Alega, em suma, que:

a)não há cobertura legal ou contratual para fornecimento de medicação de uso domiciliar;

b)o contrato pactuado pela autora é antigo e não adaptado, não se lhe aplicando a Lei n.° 9.856/98;

c) a cláusula VI, item 6.27, exclui a cobertura de tratamentos não previstos expressamente nos termos do pacto;

d) a 4ª (quarta) Turma do STJ fixou entendimento no sentido de que as operadoras de saúde não estão obrigadas a custear procedimento não incluído no Rol da ANS;

e) outrossim, o STJ fixou o entendimento de que é lícita a exclusão de fornecimento de medicação de uso domiciliar em saúde suplementar, exceto os antineoplásicos de uso oral, a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no Rol da ANS, nas quais o presente caso não se encontra;

f) inexiste qualquer fato ensejador de indenização por danos morais, já que agiu na mais estreita legalidade e respeitou os limites contratualmente estabelecidos.

Juntou documentos.

Deferida a tutela provisória de urgência (ID 88140133), a parte ré fez prova de seu cumprimento (ID 89340459) e noticiou a interposição de agravo de instrumento (ID 89703012).

Intimada, a parte autora não apresentou réplica (ID 94398434).

As partes não demonstraram interesse na produção de provas complementares (IDs 95932795 e 97354934).

É o que importa relatar. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do disposto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas. Destaque-se ainda que, conquanto intimadas para especificar as provas cuja

produção tivessem interesse, as partes nada requereram.

Da preliminar de chamamento ao processo

Sustenta a operadora demandada ser o Estado de Pernambuco o responsável pelo fornecimento de medicação de administração domiciliar, razão pela qual requer o seu chamamento ao feito.

Nos termos do art.130 do CPC/2015, é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

No caso apresentado nos autos, tenho que o requerimento de chamamento ao processo formulado pela ré não se enquadra nas hipóteses em questão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Do mérito

O laudo médico de ID 86785797 indica que: a) a autora padece de osteoporose em progressão, com perda da massa mineral óssea, a despeito do tratamento efetuado por 5 (cinco) anos com bisfosfonato; b)necessita fazer uso de prolia (Denosumabe) como alternativa de tratamento, considerando-se o elevado risco de fraturas ao qual a paciente está exposta; c) a paciente encontra-se frágil, sarcopênica, e com intolerância gástrica ao bifosfonato (que não traz mais benefícios ao tratamento); d) eventual fratura osteoporótica, diante do seu estado de saúde, poderá precipitar além de dor e desconforto, perda drástica de funcionalidade e risco de morte.

Entre os motivos da negativa de cobertura, aduziu a operadora demandada que o contrato é antigo e não adaptado, não se lhe aplicando a Lei n.° 9.856/98, e que a cláusula VI, item 6.27, do contrato firmado entre as partes exclui a cobertura de tratamentos não previstos expressamente nos termos do pacto. Outrossim, ainda que ao caso coubesse a aplicação de Lei dos Planos de Saúde, não haveria cobertura para tratamento medicamentoso em regime domiciliar.

De fato, o contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária a autora foi celebrado antes da entrada em vigor da Lei n° 9.656/1998 e não foi a ela adaptado, sendo certo que, à luz do entendimento firmado pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)n. 1931, as disposições da Lei n° 9.656/1998 são inaplicáveis *in casu*.

Em sessão do dia 7.2.2018, **o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgando parcialmente procedente a ADI n. 1931**, que questionava a Lei n° 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), considerou válida a maioria dos dispositivos questionados, mas entendeu que **os contratos celebrados antes**

da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde. No particular, o acórdão encontra-se assim ementado: "Os planos de saúde submetem-se aos ditames constitucionais, à legislação da época em que contratados e às cláusulas deles constantes".

Todavia, ainda que afastada a aplicação da Lei nº 9.656/1998, não se pode olvidar que o contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, subsumindo-se à Lei nº 8.078/1990, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

O Código de Defesa do Consumidor erigiu a boa-fé a princípio de primeira grandeza na proteção contratual do consumidor e, como corolário seu, o direito à informação clara e precisa sobre produtos e serviços (arts. 4º, III e 6º, III, da Lei 8.078/90). Cuida-se aqui da boa-fé objetiva, vale dizer, aquela segundo a qual consumidor e fornecedor devem procurar o equilíbrio contratual e pautar-se pelo respeito, pela lealdade e pela transparência recíprocos. Daí porque o fornecedor, dominador das informações especializadas sobre o produto e o serviço, deve adotar medidas úteis e eficazes para não passar ao consumidor uma ideia aparente ou incompleta acerca do produto ou serviço que comercializa.

Importa realçar que direito à informação significa clareza e precisão quanto ao real e efetivo conteúdo do contrato. Exige-se, por seu turno, cláusulas redigidas sem fórmulas e conceitos abstratos, de difícil entendimento para os leigos ou para quem não detém informações especializadas sobre os produtos e serviços.

Tal exigência, tem ainda maior razão de ser nos contratos de adesão, em relação aos quais dispõe o art. 54, § 3º, CDC: "os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor". Em sentido idêntico, o § 4º do mesmo dispositivo afirma que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".

No que se refere especificamente à matéria sobre a qual versam os presentes autos, forçoso reconhecer que a cláusula contratual invocada para a recusa de cobertura ao tratamento medicamentoso, vale dizer, a cláusula que determina a exclusão de todo tratamento, exame ou internação não previstos, expressamente, no contrato (Cláusula VI, item 6.27 – ID 84688850 – pág.2), encontra-se redigida de forma imprecisa e demasiadamente genérica, não permitindo ao consumidor compreender o seu real alcance e sentido.

Ao se comprometer com o tratamento de determinada enfermidade, a operadora cria, no consumidor, a legítima expectativa de que terá acesso aos meios terapêuticos prescritos para debelar – ou minimizar – os efeitos da patologia enfrentada. Impedir que a autora tenha acesso ao tratamento em razão de o fármaco prescrito ser ministrado em regime domiciliar **é medida inegavelmente abusiva.**

Com o paulatino avanço da medicina, muitos protocolos vêm sendo simplificados, de modo que tratamentos que antes exigiam internação ou que eram realizados em clínicas, inclusive com risco de exposição do paciente a infecções as mais diversas, **vêm sendo substituídos por injeções administradas pelo próprio paciente em ambiente domiciliar** ou mesmo por medicação oral. É exatamente o caso dos autos.

Em casos tais, a negativa de fornecimento de fármaco para administração em ambiente domiciliar levaria a situação de inaceitável iniquidade, em que o paciente haveria de permanecer em leito hospitalar ou mesmo dirigir-se à clínica, sob pena de lhe ser negada a cobertura, quando, na verdade, o tratamento se afigura mais eficaz se realizado independentemente de internação.

Saliente-se que o medicamento PROLIA (denosumabe) está registrado na ANVISA sob o n.º 102440013[1], e que na bula é indicada a sua utilização em casos de osteoporose pós-menopáusica, especificando-se que, em relação a essa patologia, a medicação aumenta a densidade mineral óssea (DMO), e reduz a incidência de fraturas de quadril, de farturas vertebrais e não vertebrais.

Ainda que o contrato pactuado pelas partes não se submeta ao rol de procedimento e de eventos em saúde da ANS, porquanto antigo e não adaptado, tenho que as operadoras de planos de saúde não podem se recusar a custear determinado tratamento/procedimento única e exclusivamente sob a alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, quando imprescindível para o tratamento do beneficiário, segundo o médico assistente, como ocorre *in casu*.

A Terceira Turma do STJ permanece tomando por exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Nesse sentido, confira-se:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.2. **O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.**3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos

> probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03

Destaque-se que, ainda que se conclua, à vista do julgamento do REsp 1733013/PR – Quarta Turma do STJ, que o rol de procedimento e eventos em saúde emanado da ANS não é meramente exemplificativo, aquele julgado ressalvou a cobertura de tratamento efetivamente imprescindível para a saúde do beneficiário, ainda que não previsto no rol de procedimentos.

Desse modo, quer se conclua, quer não, pela taxatividade do rol procedimentos e eventos em saúde da ANS, *in casu*, ainda que o contrato pactuado pela autora fosse adaptado à Lei 9.656/98, a demandada teria que garantir o tratamento médico pretendido nestes autos, dado que imprescindível para a saúde da autora.

A propósito, apesar de a parte ré argumentar a licitude da sua conduta, com base em decisões recentes do STJ que fixaram entendimento segundo o qual é lícita a exclusão de fornecimento de medicação de uso domiciliar em saúde suplementar, exceto os antineoplásicos de uso oral, a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no Rol da ANS, dentre as quais o presente caso não se encontra, é preciso pontuar que essas decisões não possuem caráter vinculante. E, repito, o contrato pactuado pela autora não se submete às disposições contidas na Lei 9.656/1998 e consequentemente ao rol da ANS.

Ademais, há precedentes recentes reafirmando a tese de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Confira-se:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. **O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato"** (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira

Turma, DJe 1°/4/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. No caso, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1903810 SP 2020/0287485-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1°, II, 35-F E 35-G DA LEI N. 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 2. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 1.1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu. 2. **De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.**(AgInt no REsp 1849149/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1498485 PE 2019/0130184-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

RECURSO ESPECIAL N° 1.795.448 - SP (2019/0030083-0). RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ADVOGADOS: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754. FRANCIS QUEIROZ PAES - SP394625. RECORRIDO: I M (MENOR) REPR. POR: R M. ADVOGADO: ADRIANO BLATT - SP329706. DECISÃO. Trata-se de recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso

III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 231): Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurado diagnosticado com hipopituitarismo (deficiência do hormônio do crescimento - GH). Prescrição médica positiva a tratamento com o medicamento Norditropin nordiflex. **Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1°, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Ministração domiciliar do fármaco, ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula n° 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe- se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente.** Sentença mantida. Recurso desprovido. Os embargos de declaração opostos (e-STJ fls. 244/247) foram acolhidos (e-STJ fls. 249/252) para sanar a omissão referente aos honorários recursais, conforme ementa a seguir redigida (e-STJ fl. 250): (...). Nas razões do especial (e-STJ fls. 257/272), a recorrente alegou violação do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, sustentando a impossibilidade de custear tratamentos e medicamentos prescritos pelo médico da recorrida, por serem utilizados em ambiente domiciliar e estarem tais tratamentos fora do rol da ANS. Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 278/288). Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fls. 299/300). É o relatório. Decido. Constata-se que o entendimento do Tribunal a quo concorda com a jurisprudência do STJ, no sentido de ser abusiva cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicação somente pelo fato de ser ministrada em ambiente domiciliar. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda queministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.064.435/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REEMBOLSO DEVIDO. HOSPITAL CREDENCIADO. RECUSA DA TABELA PADRÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. Precedentes. (...) 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 885.772/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES Desembargador convocado do TRF 5ª Região , QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe

31/10/2017.) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 04 de abril de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/04/2019).

Demais disso, resta pacificado na jurisprudência do STJ que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, **não estando a seguradora habilitada, nem tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.** Isso porque a seguradora não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica. Assim, se a patologia está prevista no contrato, não pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo.

Confira-se:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n ° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato.* **Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente.** *E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto* **quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor.** *Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n ° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n ° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da*

micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor" (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 29/06/2007).

No mesmo sentido ainda STJ - Resp. 1.053.810-SP.

Nesse contexto, ao tempo em que **tomo por injusta a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso em regime domiciliar** solicitado pelo médico assistente, **confirmo os efeitos da decisão antecipatória de tutela** deferida nos autos.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá não só danos materiais, mas também morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela autora e prescrito pela sua médica assistente, em razão do diagnóstico de osteoporose, da ineficácia do tratamento anterior e de sua frágil condição de saúde, foi suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometida a paciente.

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que a promovente, já extremamente desgastada física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparada justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-la nessa circunstância.

Ora, quem se vincula a contrato de assistência à saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, objetiva reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, visa motivar o ofensor a adotar novas práticas, cercando-se de novos cuidados, a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, tenciona impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do quantum indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP).

No caso dos autos, tenho que a demandada agiu com culpa grave, pois quando da desídia em autorizar o tratamento da autora, **tinha ciência das complicações do seu quadro de saúde, do risco de fraturas, dores, desconfortos e mesmo de morte.** Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a ré com culpa grave.

Por outro lado, a demandada é empresa de significativo porte financeiro. Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que os fornecedores em geral lucrem com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali, arcarem com indenizações a aparelharem-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à parte autora a justa reparação pelos danos sofridos, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, julgo procedentes os pedidos (art. 487, I do CPC/2015) e, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, condeno a demandada **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO** a:

1.custear o tratamento com a medicação PROLIA (Denosumab) 60mg/ml, de uso domiciliar, por tempo indeterminado, na frequência de 1 (uma) injeção subcutânea a cada 6 (seis) meses, conforme prescrição médica;

2. pagar à demandante, a título de indenização por danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1°, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

3. pagar ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela demandante, que corresponde à soma do valor da indenização por danos morais com o valor dos custos do tratamento médico cuja cobertura foi imputada à ré, tudo com fulcro no art. 85, §2°, do CPC/2015 e na Súmula 27 do TJPE.

4. pagar a totalidade das custas e despesas processuais, que devem ser recolhidas diretamente aos cofres públicos, posto que não chegaram a ser adiantadas pela parte autora, à qual foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Deve a parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, comprovar nos autos o pagamento das custas processuais que lhe é cabível. **Disponibilidade a Diretoria Cível a guia de pagamento de custas.**

Decorrido o prazo sem pagamento: a) intime-se na forma do art.22 da Lei n° 17.116/2020 (Nova Lei de Custas); b) oficie-se à Fazenda Estadual, dando-lhe ciência da existência do crédito em favor do Estado de Pernambuco; c) oficie-se, à Presidência do Tribunal, em atenção ao Provimento n°007/2019, do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em caso de enquadramento do devedor nas hipóteses previstas em seu art.1°.

Em face da pendência de julgamento do agravo de instrumento n°0017417-49.2021.8.17.9000, expeça-se ofício ao Gabinete do Exmo. Des. Relator informando acerca do julgamento do presente feito.

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art.1.023, § 2º, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, recebo-o nos seus regulares efeitos e determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1º, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §2º, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo, independentemente de juízo de admissibilidade, de acordo com o art. 1010, §3º do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação. Intimem-se.

Recife/PE, data da assinatura digital.
Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA
31/03/2022 12:58:01
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 101845745

22033112580132600000099627691

IMPRIMIR GERAR PDF